

1501540-73.2019.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2225680/2019 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1023/2019 -

DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2225680 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 1023/19/100 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501540-73.2019.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501540-73.2019.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2225680/2019 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1023/2019 -

DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2225680 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 1023/19/100 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIENE BRAGA MORALE

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LUCIENE BRAGA MORALE imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 05 de agosto de 2019, por volta das 16h30min, na Rodovia Marechal Rondon, na altura do km 631, nesta cidade e comarca de Andradina, a ré, qualificada a fls.08/09 e 17/20 dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios com pessoas até aqui não identificadas, adquiriu em outro Estado da Federação, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 40 pacotes de "maconha", com peso aproximado de 10,270kg, (cf. auto de constatação provisório de fls.26/30), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e Regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2019 em decisão de fl.87. A ré foi

citada e apresentou resposta à acusação de fls.80/84.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da denúncia e, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, regime menos gravoso de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/02, btermo de depoimento de fls.03/06, termo de interrogatório de fl.08, boletim de ocorrência de fls.13/16, autos de exibição e apreensão de fls.21/23, fotografias de fls.28/31, laudos periciais de fls. 69/71 e 103/108), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

O policial militar rodoviário e testemunha Erveson Lício Gonçalves relatou que, ao abordar passageiros de um ônibus interestadual, percebeu que a ré ficou confusa ao responder perguntas sobre a viagem, de primeiro momento afirmou que iria visitar determinado parente em Belo Horizonte, logo após, disse que na verdade estava indo dar a notícia do falecimento de outro parente, disse ainda que não tinha telefone nem endereço do parente. Ao ser questionada sobre a existência de bagagens no compartimento próprio, negou, porém os policiais verificaram no controle do motorista que havia sim uma bagagem, a ré então tirou o ticket da meia e apresentou-o aos policiais, que ao abrir a bagagem depararam-se com 40 pacotes de entorpecentes, foi quando a ré informou que receberia no montante de R\$ 1.000,00 (mil reais) para transportar a droga de Ponta Porã até Belo Horizonte.

A testemunha e policial militar rodoviário Hércules Demétrio Pereira afirmou que, ao fiscalizar a linha dos ônibus interestaduais questionou a ré sobre a viagem, que aduziu estar indo a casa de parentes dar a notícia de falecimento de outro parente, por acharem sem nexo as respostas, a questionaram sobre bagagens no compartimento próprio, a mesma negou, porém ao conferir com o controle do motorista notaram que havia sim uma bagagem, pediram que a ré os acompanhasse, momento em que ela tirou de sua meia o ticket, ao abrirem a mala depararam-se com 40 pacotes de maconha desidratada, pesando aproximadamente 10kg. Informou que receberia o montante de R\$1000,00 (mil reais) para transportar a droga de Ponta Porã a Belo Horizonte. Interrogado, a ré narrou que saiu de sua cidade Antonio João/MS, foi a até Ponta Porã pegou a droga com um homem titulado como "gordinho", que havia entrado em contato com a ré pelo telefone e depois a prometera o montante de R\$ 1.000,00 (mil reais) para transporte da droga. Contou que comprou a passagem até Campo Grande e depois até Andradina, local em que foi abordada pelos policiais. Informou que se chegasse em Belo Horizonte tiraria o casaco para ser reconhecida, entregaria a droga, pegaria o dinheiro e compraria a passagem de volta para casa, afirmou ainda que foi a primeira, porém que já foi presa por 1 ano e processada por outros crimes.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese houve apreensão de elevada quantidade de droga (mais de dez quilos de maconha), transportada pela ré em linha de ônibus, sendo que esta confessou nas duas fases que o fazia para fins de tráfico - recebeu a droga na fronteira com o

Paraguai e levaria até Belo Horizonte.

Os policiais trouxeram relato firme e consistente sobre o desenrolar da ação, referendando o quadro de provas, sem que haja qualquer razão para desacreditar de seus testemunhos. Não demonstraram serem tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar a ré, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Diante desse contexto probatório, não são necessárias maiores digressões sobre a caracterização do fato, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso

assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($1/6$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $1/6$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de $1/8$ (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base, anotando que a quantidade de droga será sopesada na fase derradeira.

Na segunda fase, a confissão não pode conduzir a pena aquém do mínimo, entendimento cristalizado na súmula 231 do STJ.

A pena-base fica assim inalterada, ou seja, no mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, relativa ao tráfico interestadual. Sendo três os Estados da Federação pelos quais a ré passaria (foi longo o trajeto, já que ia de Ponta Porã-MS até Belo Horizonte-MG), razoável incremento em patamar pouco acima de $1/6$, já que não seria isonômico aplicar o mesmo patamar àquele que vai apenas de um Estado a outro. A conduta mostra-se mais grave, inclusive pela maior necessidade de recursos, disposição e vontade para prática do crime. Assim, utilizo o patamar de $1/5$ e levo a pena a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, curvo-me à atual jurisprudência nacional, que ante a miríade de casos de tráfico de droga, optou pelo caminho da menor penalização da conduta, mesmo sendo tão presentes os deletérios efeitos da venda de drogas em nossa sociedade, cujas consequências danosas se refletem em diversas esferas, seja pela prática de inúmeros crimes, envolvendo inclusive corrupção estatal, seja pelo abandono de crianças e adolescentes filhos de usuários, problemas de saúde pública

etc.

Assim, a aplicação do redutor, que a meu ver deveria ser a exceção, tornou-se a regra, praticamente automatizada, em interpretação que deixa de observar a própria Constituição da República, a qual deu tratamento bastante enfático e especial a este crime, o estabelecendo como um dos mais graves de nosso ordenamento – vide artigos 5º, XLIII e LI, 144, II e 243, parágrafo único. E, como se sabe, a interpretação das normas infralegais deveriam partir da Constituição, e não o contrário.

De toda forma, à míngua de provas mais consistentes e seguras sobre a efetiva dedicação a atividades criminosas, já que o simples transporte de drogas não é revelador de inequívoca dedicação a atividades criminosas, nos termos do que se vem decidindo, mas sopesando o caráter da infração e a quantidade de drogas, reduzo a pena em metade, estabelecendo-a definitivamente em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime (grande quantidade de drogas e caráter interestadual), quantidade de pena e primariedade, deve ser o intermediário, semiaberto.

A substituição da pena, apesar de não vedada, não se mostra recomendável para suficiente reprovação e prevenção do delito, razão pela qual nego o benefício.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO LUCIENE BRAGA MORALE, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. Recurso em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Comunique-se, ainda, a condenação ao Poder Judiciário e Instituto de Identificação do Mato Grosso do Sul.

Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos demais bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491. Caso sejam inservíveis, fica desde já autorizada a destruição/inutilização de modo ambientalmente correto.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 18 de julho de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)